

1500487-53.2021.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... no período noturno, para local de tráfico, sem sequer saber o prenome da pessoa de quem adquiriria a droga. De igual modo, vale destacar que, embora o pai do acusado tenha relatado que seu filho sempre foi usuário de drogas, nada mencionou quanto ao antecedente infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que também reduz a confiabilidade da versão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia-SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500487-53.2021.8.26.0035 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500487-53.2021.8.26.0035

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321905/2021 - DEL.POL.AGUAS DE LINDOIA, 21618402 - DEL.POL.AGUAS DE LINDOIA, 407/21/101 - DEL.POL.AGUAS DE LINDOIA, 2321905 - DEL.POL.AGUAS DE LINDOIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO SANTANA DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de Alexsandro Santana de Lima, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Narra-se na denúncia, em resumo, que "No dia 26 de novembro de 2021, por volta da 1 hora, na Rua Domingos Lazari, no município de Lindóia, ALEXSANDRO SANTANA DE LIMA trazia consigo e guardava, para fins de consumo de terceiros, 12 porções de maconha, pesando cerca de 13g; 26 porções de cocaína, com peso aproximado de 56g; e 21 pedras de crack, pesando em torno de 10g, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autode exibição e apreensão de fls.

12/13, auto de constatação provisória de fls. 14" (fls. 74/76).

A denúncia foi recebida em 18/03/2022.

Promovida a notificação (fls. 114), Alexsandro Santana de Lima apresentou defesa prévia (fls. 84/91).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo laudo de exame pericial (Entorpecentes - fls. 140/142), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. Constam dos autos, ainda, os seguintes elementos probatórios: laudo de exame pericial - Escolher um item. (fls. número); laudo de exame pericial - Escolher um item. (fls. número); fotos das drogas apreendidas, fls. 30/33.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha (policial civil) Vagner de Oliveira Preto relatou que em investigação no bairro Casas Populares, em torno da meia noite, foram ao local e ficaram em um local campanando à distância, quando viram Alexsandro; que chegaram carros, ele ia ao carro, conversava com a pessoa, ia até o mato, retornava com a droga e entregava ao conductor do veículo; que depois disso em momento oportuno o abordaram, encontraram R\$ 60,00 no seu bolso e nos arbustos acharam porções de crack, cocaína e maconha em uma sacolinha; que então o conduziram à delegacia; que não o conhecia; que ele falava palavras desconexas, não fazia sentido por que ele estaria ali, não soube explicar; que havia movimentação na rua de pessoas que iam comprar droga; que no corpo dele não havia droga; que acharam uma sacola em um arbusto, com drogas; que não conseguiram abordar usuários;

A testemunha (policial civil) Antonio Morgado Neto relatou que foram até as Casas Populares em rua conhecida por tráfico e onde já fizeram várias prisões; que ficaram em observação de longe, viram Alexsandro indo em direção aos veículos, retornando até uma moita próxima à gruta e retornando de novo fazendo entrega aos veículos; que ficaram uma hora observando; que decidiram abordá-lo, localizaram dinheiro com ele e na moita localizaram a sacola com as drogas; que então foram à delegacia e apresentaram a ocorrência; que não o conhecia; que acha que ele falou que não era da cidade; que ali não tem ponto de ônibus, nada, não tinha por que fazer o movimento de ir à gruta e à rua várias vezes.

Por fim, o acusado relatou que nessa noite veio a pé pelo Themas, tinha passado o dia inteiro com reciclagem; que pegou uma pedra de crack, foi para o mato, fumou, saiu para comprar mais para ir embora, aí tinha mais um tanto de gente que ia pegar também; que foi quando os policiais que fizeram a curva e o rapaz que estava vendendo correu, e só ficaram eles; que foi algemado pelo pé; que ele foi liberando todo mundo; que foi quando ele saiu do mato com uma sacola e disse que era dele; que ia pegar mais entorpecente com o rapaz que estava vendendo; que ficaram ele e mais cinco pessoas; que essas pessoas também estavam para comprar droga; que sabia porque estava todo mundo louco; que o rapaz que estava vendendo é moreno, alto, por nome não conhece; que só veio aqui duas vezes, no dia da abordagem e um mês; que estava com R\$ 60,00; que ia comprar quatro pedras, cada uma dez reais; que ia voltar a pé, são quatro quilômetros pela estrada; que não conhecia os policiais, nunca viu; que os policiais tinham que pegar alguém, aí eles escolheram; que tinha tido um problema com sua esposa e com a discussão saiu de casa, por quase dois meses, e naquele momento não tinha lugar fixo para ficar.

Verifica-se, pois, que o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem do acusado após ter sido visualizado em local mencionado em denúncia anônima, com características correspondentes a de indivíduo mencionado como traficante em denúncia anônima, e após ter corrido e dispensado uma sacola em um matagal, para onde fugiu correndo. A contradição dos policiais é pontual e limitada à circunstância de o policial Daniel ter dito que estava sozinho e de o policial Carlos ter dito que havia duas pessoas no local. A rigor, não está afastada a possibilidade de simples interpretação divergente dos fatos, pois o próprio acusado disse que não estava junto do outro rapaz que estava no local. Tal diferença dos relatos não é suficiente para infirmar a confiabilidade das narrativas dos policiais. A conduta percebida pelos policiais não é compatível com o uso de drogas, tendo em vista a vultosa quantia de dinheiro apreendida em seu poder, sem origem lícita comprovada, bem como a apreensão de três espécies distintas de droga em sacola que foi por ele dispensada em ermo matagal.

Já quanto à hipótese alternativa defensiva, mostra-se de reduzida confiabilidade e verossimilhança. Em primeiro lugar, como o próprio acusado ressaltou em audiência, não frequentava a cidade de Águas de Lindoia e não conhecia os policiais que efetuaram a abordagem. Logo, é nula ou no mínimo remota a probabilidade da hipótese de que os policiais tenham promovido flagrante forjado da forma como alegou o réu em autodefesa: ao perseguir (e imotivadamente abandonar a perseguição) do traficante que teria fugido da viatura, teriam os policiais abordado o acusado sem um grama de droga sequer e, mesmo não o conhecendo previamente, teriam imputado drogas a si de forma falsa. De igual modo, não é razoável que tenha o acusado comparecido a Águas de Lindoia com vultosa quantia em dinheiro em espécie (R\$ 2.300,00) em sua posse, conforme alegado. É oportuno destacar que não foi promovida a qualificação e o arrolamento do empregador, "Felipe", para oitiva como testemunha, a fim de corroborar a afirmada origem ilícita de tal substancial quantia de dinheiro. Também impressiona a versão defensiva de que o acusado, que tem renda mensal aproximada de R\$ 2.500,00, teria pagado também vultosa quantia (R\$ 200,00, mais presumidos R\$ 200,00 para retorno) para vir à cidade no período noturno, para local de tráfico, sem sequer saber o prenome da pessoa de quem adquiriria a droga. De igual modo, vale destacar que, embora o pai do acusado tenha relatado que seu filho sempre foi usuário de drogas, nada mencionou quanto ao antecedente infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que também reduz a confiabilidade da versão defensiva.

Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de transportar, como no caso dos autos.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (ratio cognoscendi) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que os acusados praticaram conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59

e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes demonstra a existência de mais de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), a qual também configura reincidência (CP, art. 64). Assim, a fim de evitar punição dúplici pelo mesmo fato (*bis in idem*), uma delas será considerada como reincidência na segunda fase e as demais como antecedentes negativos nesta primeira fase (cf. Súmula 241/STJ e STJ, REsp 1.794.854/DF). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame. Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais uma espécie de substância ilícita (maconha, crack e cocaína), de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Quanto à quantidade de droga apreendida em poder de Douglas, houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita (quase um quilo de cocaína) suficiente para a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e incide a agravante da reincidência.

Na segunda fase da dosimetria, não há limites legais mínimo e máximo de agravamento ou atenuação de pena previamente estipulados nos arts. 61 a 66 do CP. Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação da fração de 1/6 como patamar mínimo das causas de aumento/diminuição de pena constantes do Código Penal, consolidou-se a fixação da fração de 1/6 como referencial para o agravamento ou atenuação da pena em razão de cada circunstância legal, de modo que "a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). Nesse sentido, a orientação é a de que "a reincidência específica autoriza a adoção de fração maior que 1/6 na segunda fase da dosimetria" (STJ, HC 480.406/SC, Sexta Turma, DJe 25/04/2019).

Assim, agrava-se a pena em 1/6, de modo a resultar na pena intermediária de 7 anos, 3 meses e 15 dias, mais 729 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Quanto à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a sua incidência depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa.

No caso, a reincidência obsta a incidência da minorante.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve

atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade e a reincidência, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado, com base no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP e observadas as Súmulas 718 e 719/STF e 269 e 440/STJ.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu em razão das circunstâncias judiciais negativas. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado ALEXSANDRO SANTANA DE LIMA ao cumprimento de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 729 dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33 e 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 65, III, "d" do CP.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação no acórdão do Tribunal de Justiça permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único). Quanto à arma de fogo e às munições apreendidas, deve ser decretada a perda em favor da União. Encaminhem-se ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade, em relação ao acusado Emerson, em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

PIC.

Águas de Lindoia, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA